

1502976-78.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... e comarca, RODRIGO SILVA DE MELO, qualificado a fls. 07/08, FERNANDO ALVES DA MOTA, qualificado a fls.09/10, e FELLIPE DE FREITAS PEREIRA, qualificado a fls. 11/12, associaram-se para o fim de cometerem crimes; [B] consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta até o dia 27 de agosto de 2022, nas dependências da Empresa CMOC, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502976-78.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502976-78.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235106/2022 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 27047197 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2235106 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELLIPE DE FREITAS PEREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais¹, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra RODRIGO SILVA DE MELO, FERNANDO ALVES DA MOTA e FELLIPE DE FREITAS PEREIRA, tendo-os por incursos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c art. 7, caput , e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal , imputando-lhe os seguintes fatos: [A] consta do incluso inquérito policial que, desde data incerta até o dia 27 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca, RODRIGO SILVA DE MELO, qualificado a fls. 07/08, FERNANDO ALVES DA MOTA, qualificado a fls.09/10, e FELLIPE DE FREITAS PEREIRA, qualificado a fls. 11/12, associaram-se para o fim de cometerem crimes; [B] consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta até o dia 27 de agosto de 2022, nas dependências da Empresa CMOC, nesta cidade e comarca de Cubatão, RODRIGO SILVA DE MELO, qualificado a fls. 07/08, FERNANDO ALVES DA MOTA, qualificado a fls.09/10, e FELLIPE DE FREITAS PEREIRA, qualificado a fls. 11/12,

agindo previamente ajustados e com identidades de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, 37 (trinta e sete) toneladas de adubo, avaliada em R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21 e 21 pertencentes à Empresa CMOC. Recebida a denúncia em 27/09/2022 [fls. 280/281], os réus foram citados [fls. 351, 385 e fls. 463] e, por intermédio de Defensores constituídos [réus Rodrigo e Fernando] e nomeado [Réu Fellipe], apresentaram resposta à acusação [fls. 234/240, 363/368 e 464/467].

Afastada a possibilidade de absolvição sumária [fls. 518/520], em audiência foram colhidos o depoimento das testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência [fls. 13/17], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 20/21], pelo auto de entrega [fls. 24], pelos documentos de fls. 25/72, pelo laudo pericial [fls. 285/286] e pela prova oral sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelas declarações do ofendido, reconhecimento pessoal, depoimento de testemunhas e confissão.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelos depoimentos de testemunhas.

A tese defensiva, como se verá, está isolada nos autos.

David Santos Alvarez, representante da vítima, declarou ter recebido denúncia reportando, em 5 de agosto de 2022, desvio de produto acabado. Avaliação de imagens permitiu concluir pela saída de mercadoria da empresa sem nota fiscal respectiva. No dia dos fatos [20 de agosto de 2022], Fernando, motorista, conduziu caminhão carregado e foi acompanhado até descarregamento na cidade de Platina-SP. No dia dos fatos, Fernando era motorista; Rodrigo, conferente [direciona o condutor e auxilia carregamento]; e Fellipe, formalizando o peso do veículo e emitindo nota fiscal. A prisão em flagrante ocorreu aproximadamente cinco minutos após a saída do caminhão da empresa, na via pública. A carga foi recuperada no mesmo dia. Não houve faturamento da mercadoria no caminhão apreendido. Fernando, o motorista, conduziu caminhão carregado com o auxílio de Rodrigo sem respectiva "ordem de carregamento", acessando a via pública após falsa pesagem com o auxílio de Fellipe, o que foi possível porque ausente supervisão da sua atividade e equipamento obstativo do controle de tráfego da saída. Por fim, mediante nota fiscal falsa, o motorista conseguiu autorização para acessar a via pública.

A testemunha Danilo Sotero declarou ser funcionário de empresa terceirizada que presta serviços para a empresa CMOC. Declarou conhecer os acusados Felipe e Rodrigo. Não conhece Fernando Santos Alves da Mota. O depoente no dia dos fatos chamou Rodrigo na empresa a pedido do encarregado, porque operaram em turno de 24 horas, estava de folga no dia dos fatos, era um sábado à tarde, recebeu informações do encarregado de plantão que a polícia civil estava no local e solicitava o retorno do Rodrigo à empresa. O depoente telefonou e Rodrigo prontamente aceitou retornar. O depoente presta serviços à empresa CIMOC há cinco anos e meio. O depoente, salvo engano, entrou antes do Rodrigo na empresa CIMOC. O depoente começou a trabalhar para a CIMOC em maio de 2017. Nunca recebeu comentários ou desconfiança que desabonasse Rodrigo. O encarregado que telefonou para o depoente foi Ruan Alves. Na operação de carga/descarga da CIMOC dependente do dia da semana

e horário, mas em média 35 pessoas por turno, ou 100 pessoas em média por dia. Do carregamento até a saída do caminhão o tempo dependerá do tipo de carga. Na área de fertilizantes, em que Rodrigo trabalhava, atuam até seis pessoas em média. Os setores são distribuídos: dois recebendo o caminhão, dois durante o carregamento e dois durante o faturamento. O procedimento de entrada se inicia no pátio de caminhões, uma portaria é administrada por outra terceirizada, a Guardiã, com vigilantes. São responsáveis pela fiscalização do veículo e autorização para acesso ao pátio de caminhões. Dentro do pátio tem a empresa LC Logística atuando com marcação de caminhões e vistorias de caminhões (se estão em condições de carregamento). Esse setor aciona o setor de fertilizantes e a disponibilidade do veículo que é ou não chamado. Com a liberação, a equipe de marcação registra um TAC. O veículo entra em outra portaria, também administrada pela Guardiã, nova fiscalização, é encaminhado para uma balança de entrada automática (sem operação humana), segue para carregamento e finalizado o conferente assina a remessa e o motorista pesa na balança de saída. O assistente de logística é o responsável pela conferência da documentação e liberação do motorista. Uma vez liberado o motorista, desce da balança, o vigilante registra a saída e segue a viagem. Para carregar o motorista deve apresentar ordem de carregamento. A equipe de marcação não verifica o carregamento. No dia dos fatos, as balanças da CMOC precisam de manutenção preventiva, por isso, algumas estavam com cancela inoperante, mas isso não impedia a operação do dia. Os conferentes e balanceiros são supervisionados pelo encarregado do turno. Antes de liberar a nota não há supervisão. O encarregado é responsável por toda a equipe, cerca de 30 pessoas, a rotina do faturista e emissão das notas é independente. Havia relógio eletrônico na empresa, registro por biometria. Do momento em que o depoente a ligação e o retorno do Rodrigo à empresa não deve ter demorado por mais de 30 minutos. Não sabe se Fernando foi preso porque não o conhece.

A testemunha Elias Moraes dos Anjos declarou ter comparecido o representante legal da CMOC noticiando investigando interna da empresa sobre desvio de carga. Diante dessa informação, a chefia enviou equipe a campo para verificar a veracidade dessa investigação interna da empresa CMOC. Foi informado horário e data em que haveria desvio de carga. Dirigiram-se no dia 27 ao local próximo onde haveria o desembarque do caminhão. Chegando ao local, verificando caminhão Scania deixando a empresa e fizeram a abordagem. Solicitada a documentação, o motorista Fernando apresentou e averiguando a documentação, notaram estar regular a documentação do caminhão e da carreta, mas havia nota fiscal com data do dia 27, mas horário diferente, das 22 horas com quantidade de 31 toneladas de produto. Questionado, o motorista informou ser a nota necessária para transporte da carga e os policiais retornaram para a empresa. Na empresa, os policiais conversaram com Felipe quem informou ser uma nota fiscal de caminhão que saía e “seguravam ela”. Mantiveram contato com Rodrigo também. Todos foram conduzidos para delegacia porque todos declararam que estavam desviando a carga. O delegado adotou as providências. O depoente não teve acesso aos documentos da investigação interna da empresa. O depoente participou da parte operacional. O depoente é policial civil há 35 anos. O depoente trabalha atualmente na delegacia de roubo, furto e desvio de carga, faz parte do DEIC, âmbito estadual. É comum o deslocamento de policiais da cidade de São Paulo para outras cidades. Há parte burocrática relativa à elaboração da documentação necessária para a viagem. Nesse caso houve ofício de viagem e a ordem de serviço foi suprida pela denúncia da empresa CMOC. Não se recorda se Fernando informou sobre outras pessoas envolvidas no momento do flagrante, se comentou, não foi com o depoente. Felipe e Rodrigo não falaram sobre confissão sobre os fatos, outro colega era responsável por isso. O depoente era responsável pelo apoio logístico. O depoente foi escalado porque sua equipe estava escalada para o plantão, coincidiu do representante legal da CMOC ter comparecido no local neste dia. Não conhece ou conhecia os réus. A equipe, a princípio, abordou o motorista do caminhão. A nota fiscal não condizia com a carga, destino e horário da mercadoria. A abordagem foi às 16h00 e a nota fiscal era de 22 horas. Outro colega, Sr. Jairo, foi responsável por fazer o contato com os funcionários da empresa. A voz de prisão foi dada, após a informação prestada pelo Sr. Jairo, obtida com o funcionário responsável pela investigação interna. O

depoente permaneceu no pátio e o Sr. Jairo estava próximo à balança e o depoente próximo ao caminhão. A prisão do Fellipe foi feita pelo colega do depoente. Rodrigo tinha acabado de sair e um encarregado ligou pedindo que ele voltasse à empresa para prestar esclarecimentos sobre problema que havia na empresa e foram conduzidos à delegacia. Todos permaneceram em silêncio. A carga como estava na carreta e com excesso de peso, não tinha como fazer o transporte. Houve determinação que permanecesse na empresa mediante auto de depósito. Não havia investigação dos acusados pelo departamento policial. A equipe chegou na CIMOC por volta das 16 horas que era horário que ocorria o delito. Não tem acesso ao nome do representante da empresa CIMOC. Foi advogado que foi até o DEIC para comunicar a existência da investigação interna. Existe em Santos com a reformulação do governado as DIG's que atuam no litoral e Cubatão faz parte. Não sabe por que foi transferido para DEIC DE São Paulo e não em Santos. No dia dos fatos, na portaria tinham dois seguranças, um chefe de segurança com o carro e compareceram mais dois rapazes que possivelmente eram os chefes. Não tem conhecimento de defeito na balança no dia.

A testemunha Jairo Dantas Moura, investigador de polícia, se recorda dos fatos. O representante da empresa CMOC procurou os policiais com relatório elaborado pela empresa sobre desvio de fertilizantes, repassando os dados como estava ocorrendo o desvio, foram solicitados ofícios para diligências para confirmar o quanto apurado na investigação pela empresa. Dirigiram-se ao local dos fatos, o caminhão estava em movimento fora da empresa e foi abordado. O motorista Fernando foi abordado com quem foram encontradas as notas falsas e sem documentação do fertilizante. A nota anulada era entregue para o veículo posterior. O Fernando não carregava documentação que comprovasse a carga transportada. O veículo dele estava com carga em quantidade diferente da nota na balança. Foi solicitada a presença do Rodrigo na empresa, ele retornou e todos foram conduzidos à delegacia. O caminhão e a carga ficaram na empresa. A data que estava com Fernando estava com data posterior para ser retirada e indagado Fernando confirmou ser falsa a nota. O depoente leu o relatório e nele estavam indicadas outras pessoas além de Fernando. Não sabe se estavam em outros fatos, o objetivo da equipe foi o flagrante. O Rodrigo e o Fellipe atuavam na balança. Na substituição de um deles, o outro assumia. Não foi identificada uma quarta pessoa. O crime era utilizado na balança e na expedição. No carregamento também deve haver envolvimento, mas isso não foi constatado durante a investigação. Após receber o relatório da empresa CIMOC, a diligência foi designada, o motorista foi detido fora da empresa, o caminhão estava a 200 ou 300 metros da rodovia. O depoente é policial civil há 37 anos. A delegacia em que está lotado é especializada em roubo, furto e desvio de carga, com atuação em âmbito estadual. Para atuar em outra cidade é necessário ofício de viagem e o relatório da empresa funciona como denúncia. O motorista não portava nota fiscal pertinente à carga. O motorista admitiu furto reiterado que era feito dentro da empresa. O motorista indicou os nomes de Rodrigo e Fellipe como participantes do furto de forma habitual. Não se lembra qual valor da vantagem que os acusados recebiam, mas algo em torno de R\$5 a R\$6 mil por caminhão com carga desviada. Na CMOC houve confissão do motorista Fernando dentro do caminhão, apenas. Na delegacia é que houve a confissão dos demais. O advogado chegou na delegacia após redução da confissão a termo. A incompatibilidade documental é que o motorista não tinha documentos para retirar aquele veículo, ele tinha nota fiscal de fertilizante para ser retirado depois. A notícia crime foi recebida provavelmente um dia antes da diligência, não se recorda com precisão. Na delegacia compareceu a advogada da CMOC, Veridiana Viana Chain, OAB 286.798. Durante a ocorrência, a equipe entrou em contato com o David que identificou o veículo acessando a empresa, posteriormente compareceu à delegacia advogada da empresa CMOC. Não se recorda o nome do representante da vítima que compareceu na delegacia. Quando chegaram na CMOC o Fellipe estava na balança, segundo informações Rodrigo já tinha saído e encarregou Fellipe sobre a retirada de fertilizantes. O Rodrigo veio depois à CMOC atendendo pedido do encarregado. Não sabe informar porque os representantes da empresa preferiram noticiar os fatos ao DEIC de São Paulo em vez do DEIC de Santos. Com o depoente, estava o policial Elias e o Jorge. Quem acessou o caminhão foi o depoente. A conversa com Fernando, o policial Elias não ouviu. O depoente tentou

acessar o sistema de emissão de notas da empresa, mas não conseguiram exibir. Não sabe a quantidade de caminhões no dia para carregar, porque foi abordado do lado de fora. Acredita que o carregamento é rápido e em decorrência do porte da empresa parece ser grande a movimentação de caminhões. Não sabe se tem empresa de segurança particular atuando na empresa. Não sabe se havia defeito na balança da empresa. Durante interrogatório, o réu Rodrigo Silva de Melo negou os fatos. Foi preso em 27 de agosto de 2022 sob a acusação de desvio de carga. Conhecia os demais réus do ambiente de trabalho. Possui uma motocicleta preta que pertence à sua esposa. Dirigia-se ao trabalho com o ônibus fretado da empresa. Acha que Fernando tem um carro, mas não sabe qual é, a cor é preta. Fellipe morava no Parque das Bandeiras, mas pelo que sabe ele se mudou. O depoente exercia a função de conferente, conferia as cargas, indicava box que o motorista do caminhão iria carregar, quantidade de peso e produto. O Fernando chegou no horário para carregar. O motorista apresenta a nota de carregamento. Não sabe quem expede. Quem a apresenta é o motorista. O motorista exibe, circula o peso, o armazém que irá carregar e indica o box de carregamento, só isso. Só os balanceiros informam o peso e só quando dá excesso; não havendo excesso nada é informado. Na balança o motorista entrega a nota de carregamento. Quando o motorista Fernando foi preso o depoente já tinha ido para casa. Atendeu o motorista por volta das 16h00 e a pesagem por volta das 16h30. Não tem conhecimento da divergência de horário da nota fiscal. Não sabe por qual motivo foi preso e quem carregou o caminhão não foi. Sofreu agressão na delegacia pelo delegado, branco, dos olhos claros, com murros na costela e um murro na cabeça, não ficou marca, disse que era para assinar o documento. O documento para assinar já estava pronto, digitado. Não sabe quem foi ouvido primeiro. Quando o advogado chegou o depoente já tinha assinado o documento. O advogado chegou 40 minutos depois. Os policiais não deixaram o advogado conversar com o depoente. Comunicou sobre a agressão quando foi procurá-lo para fazer a defesa dele, provavelmente dia 29 de agosto. No dia da audiência de custódia o advogado informou sobre a agressão, mas essa informação não constou no termo de audiência, o advogado do réu confirmou essas informações e declarou possuir 27 anos de carreira. Interrogado em juízo, Fernando Alves da Mota negou os fatos. Esclareceu ter ingressado na empresa com a nota de entrada, carregou o veículo e saiu. Desconhece qualquer pessoa da empresa. Fellipe é o balanceiro quem lhe deu a nota para sair com a carga. Normalmente, para o veículo na balança e desce do caminhão. O documento é entregue e, em seguida, passa pela portaria para a conferência, saindo da empresa. Quando o veículo foi pesado, viu na balança 31 toneladas, o que conferia com a nota fiscal. Quem carregou o caminhão foi Rodrigo, sendo que o conhecia apenas de carregamentos anteriores. Interrogado em juízo, Fellipe de Freitas Pereira confessou os fatos. Afirmou que se associou com os outros corréus com a finalidade de desviar cargas. O caminhão entrava na fábrica, passava pelo pátio de vistoria e, no carregamento, Rodrigo o recebia. Na balança onde estava, alterava a nota fiscal e o peso. Na data dos fatos, Fernando conduzia o caminhão, o qual foi carregado no turno anterior, momento de trabalho de Rodrigo. O caminhão já chegava com a ordem de carregamento, que são emitidas por e-mail. Tal ordem recebe o carimbo na portaria e adentra às dependências da empresa. No entanto, é possível carregamento sem ordem. Dois são os tipos de ordem, de carregamento e de carga. A ordem é verdadeira. O desvio se encontrava no faturamento. A ordem de carga é falsa. Não sabe quem confeccionou o documento falso. O campo do peso era falseado. Fernando não fiscalizava o peso. Foi convidado para a prática delitiva por Fernando e Rodrigo. Estava em sua casa, quando foi convidado, ambos foram até sua casa, e o convidaram. Eles perguntaram se queria praticar os fatos. Praticou os fatos por duas vezes, sendo uma com excesso. Ganhava na diferença de peso. Era quem liberava as notas. Outras pessoas praticavam os fatos e já foram desligados. Sabia que tinha esquema antes de participar dos fatos. Também faziam cargas lícitas. RODRIGO tem uma moto preta e FERANDO um carro preto. Recebeu R\$5.000,00 pelo crime, mas não devolveu o dinheiro, embora arrependido.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que

os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

O corréu Fellipe confessou os fatos narrados na denúncia.

A confissão foi corroborada pelas declarações da vítima e depoimento dos policiais civis, que expuseram os fatos de modo coerente e harmônico com todo o contexto probatório, especialmente mídia e investigação interna, exposta ao contraditório. Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: “Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública”. [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017]

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Desse modo, o fato alegado pelos réus não confessos [prática ordinária conforme dinâmica da empresa], sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, sobretudo ausente demonstração da lisura da ordem de carregamento e de sua efetiva adequação à carga real, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor.

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento de que estão reunidos todos os elementos da definição legal do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal [CP, art. 14].

No mais, a ausência de prejuízo em razão da recuperação do bem subtraído não afasta a tipicidade das condutas.

No mais, a prova oral torna inafastável a qualificadora do concurso de agentes descrita na denúncia, dado o auxílio mútuo para a prática do crime de furto. Também a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal [fraude], está comprovada nos autos. Conforme leciona a doutrina, “Fraude é a utilização de artifício, de estratagemas ou ardil para vencer a vigilância da vítima; em outros termos, trata-se de manobra enganosa para ludibriar a confiança existente em uma relação interpessoal, destinada a induzir ou a manter alguém em erro, com a finalidade atingir o objetivo criminoso”. No caso, a fraude consistiu na manipulação do sistema eletrônico que emite a nota fiscal após a pesagem do caminhão e da carga na balança, a menor, viabilizando a subtração do excesso.

Passa-se ao exame da imputação fática da associação criminosa, prevista no art. 288 do Código Penal.

Para a configuração do crime em epígrafe é preciso ânimo de associação de caráter estável e permanente. Nesse sentido, Nelson Hungria leciona que: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial".

É o caso dos autos.

Isso porque as provas colhidas nos autos demonstram que os réus mantinham associação estável e permanente destinada a cometer crimes patrimoniais.

Não pode ser desprezada a dinâmica da prática de furto em concurso de agentes em estabelecimento profissional de carregamento de carga.

Outrossim, o corréu Felliipe, o representante da vítima e testemunhas reportaram a divisão de tarefas na empreitada criminosa.

Assim, pois, a prova oral revela o mesmo *modus operandi* perpetrado pelos réus, a demonstrar a estabilidade da associação e a divisão de tarefas, colocando em risco a paz pública, excluindo hipótese de uma cooperação meramente eventual, mas sim de relação pautada pela estabilidade.

Segura a prova oral da recorrência da conduta, tendo o corréu confesso reconhecido a prática criminosa por duas vezes, sem prejuízo de atestar o conhecimento por sua prática anteriormente ao seu ingresso.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Possível a dosimetria conjunta, por economia processual. A propósito, confira-se:

"O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais - como no caso concreto -, realize um procedimento de dosimetria da reprimenda em separado para cada um deles, podendo, desde que o faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes forem comuns e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele quantum"

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo quanto ao corréu Felliipe. Por seu turno, quanto aos corréus Fernando e Rodrigo, forçoso reconhecer a anormalidade da circunstância, porque é maior o índice de reprovabilidade da conduta dos agentes pelo fato criminoso praticado à vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, considerando a premeditação e convite do corréu Felliipe, conduta que revela maior desvalor da ação de furto efetivamente praticado e da associação para esse fim. Os acusados não registram maus antecedentes, exceção feita ao corréu Fernando [fls. 128/130]. A conduta social e personalidade ["deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu"] [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As circunstâncias do crime são elementos accidentais ao tipo penal relevantes juridicamente, referindo-se às condições gravosas em que foi praticado, impositivas de maior reprimenda, como na hipótese em que, no furto, os agentes praticaram o delito em concurso de agentes e mediante fraude, servindo uma das circunstâncias para qualificar o delito e as outra para majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base no mínimo legal para o crime de associação. Para o corréu Fernando um

quinto de acréscimo [culpabilidade e antecedentes]. Para o corréu Rodrigo um sexto [culpabilidade].

Pena-base com acréscimo de um sexto para o crime de furto ao corréu Fellipe [circunstâncias]. Para o corréu Rodrigo um quinto [culpabilidade e circunstâncias]. Para o corréu Fernando um quarto de acréscimo [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias]

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a sopesar.

Contudo, ao corréu Fellipe, em segunda fase, verifica-se presente circunstância atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, d], inexistindo circunstância agravante a ser valorada. Assim, atenuo a pena intermediária em um sexto, no mínimo legal, para ambas as condutas, observada a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Pena definitiva de:

[a] furto qualificado:

i. para o corréu Fellipe 2 anos de reclusão com 10 dias-multa.

ii. para o corréu Rodrigo 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, com 12 dias-multa;

iii. para o corréu Fernando 2 anos e 6 meses de reclusão, com 12 dias-multa;

[b] associação criminosa:

i. para o corréu Fellipe 1 ano de reclusão;

ii. para o corréu Rodrigo 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão;

iii. para o corréu Fernando 1 ano e 3 meses de reclusão.

Desborda da denúncia imputação, originariamente em alegações finais, da prática de dois delitos de furto em continuidade delitiva.

No mais, havendo pluralidade de ações típicas com pluralidade de resultados típicos, é o caso de se aplicar o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, tornando definitiva a pena em: [a] 3 anos de reclusão com 10 dias-multa ao corréu Fellipe; [b] 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, com 12 dias-multa ao corréu Rodrigo; [c] 3 anos e 9 meses de reclusão com 12 dias-multa ao corréu Fernando.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, "quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)". Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.

Assim sendo, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto aos corréus Fernando e Rodrigo, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea c c/c § 3º, do Código Penal.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese por ausência do requisito objetivo, pelo menos.

Ao corréu Fellipe o regime será o aberto, sobretudo por sua personalidade.

Quanto ao corréu Fellipe, tendo em vista o preenchimento dos requisitos alinhados no art. 44, do CP e seu §2º, prevalecendo a personalidade sobre as circunstâncias desfavoráveis, substituo a pena privativa de liberdade imposta por 2 [duas] penas restritivas de direito, a saber: prestação de serviço à comunidade [art. 46, CP] em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais [LEP, art. 66, V, a] e prestação pecuniária [art. 45, §2º, CP] no importe de dez dias-multa a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução.

Assim, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. O local e a forma de

cumprimento da pena serão definidas pelo Juízo da Execução.

Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do artigo 44 do Código Penal, com seu recolhimento à prisão.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não se há falar em sursis.

Quanto aos demais corréus, havendo circunstância judicial desfavorável [furto duplamente qualificado], não há como conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

Igualmente inaplicável a suspensão condição da pena porque não preenchidos os pressupostos legais [CP, art. 77, II].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO:

[a] FELLIPE DE FREITAS PEREIRA, qualificado anteriormente, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com 10 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c art. 7, caput , e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal;

[b] RODRIGO SILVA DE MELO, qualificado anteriormente, às penas de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 12 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c art. 7, caput , e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal;

[c] FERNANDO ALVES DA MOTA, qualificado anteriormente, às penas de 3 anos, 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 12 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c art. 7, caput , e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Estão presentes os pressupostos fáticos de cabimento da prisão preventiva do corréu Fernando.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a reiteração de condutas criminosas imputadas ao réu, com condenação por sentença, inclusive, seria imperiosa a manutenção de sua prisão cautelar.

A compatibilidade da prisão preventiva na hipótese de regime semiaberto é controvertida na jurisprudência. Com efeito, “a prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado” [STJ, RHC 39.060-RJ, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013]. Contudo, como já se pontuou, “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena.

Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do

Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459)" [STF, HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017].

Nesse contexto, no caso concreto, a medida excepcional é compatível, à vista da possível adequação da estrutura estatal e gravidade concreta do delito [furto do excesso de carga mediante fraude em concurso de agentes no contexto de associação criminosa, sem desprezar andamento de ação penal em seu desfavor em data recente; fls. 129/130].

O réu deve aguardar o trânsito em julgado da condenação em regime semiaberto, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de execução/recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Fls. 601/602: ATENTE a secretaria.

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA